

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 203/2565 ว.  
กรมทรัพย์สินทางปัญญา

โจทก์  
จำเลย

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7, 80

คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการโดยตรงนั้นต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ว่าทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการทันที หรือหากสาธารณชนใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ เพราะเป็นคำที่บรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการนั้นโดยตรง เครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD ของโจทก์มีลักษณะเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาประกอบด้วยสองภาคส่วน คือ ภาคส่วนคำว่า "MY" มีความหมายตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai แปลว่า ของฉัน และภาคส่วน คำว่า "CLOUD" ซึ่งแม้คำนี้จะมีหลายความหมาย ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และในส่วนของความหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ก็มีความหมายที่แตกต่างกัน เมื่อการพิจารณาว่าคำในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการโดยตรงหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาประกอบกับสินค้าหรือบริการที่ขอจดทะเบียน การที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการที่มีคำว่า "CLOUD" กับบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ สาธารณชนที่พบเห็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ย่อมเข้าใจได้ในทันทีว่าเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ ดังนั้น คำว่า

"CLOUD" จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง  
ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าคำว่า "CLOUD" เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติ  
ของบริการของโจทก์โดยตรง การที่โจทก์นำคำดังกล่าวมาประกอบกับคำว่า "MY"  
ในลักษณะเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดา แยกส่วนออกได้เป็นสองคำ โดยที่คำ  
ว่า "MY" มีความหมายว่า ของฉัน ซึ่งเป็นความหมายโดยทั่วไปไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์  
กับโจทก์ เมื่อนำมาใช้ประกอบกับคำว่า "CLOUD" จึงไม่ได้เป็นการนำคำที่มีความ  
หมายตามพจนานุกรมมาใช้อย่างอำเภोजใจ แต่กลับเป็นเครื่องหมายบริการที่ไม่มี  
ลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการนั้นทราบหรือเข้าใจได้ว่าบริการที่ใช้  
เครื่องหมายนั้นแตกต่างไปจากบริการอื่น เครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD  
ของโจทก์โดยภาพรวมจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนตาม  
พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2)  
(เดิม)

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม (เดิม) บัญญัติว่า ชื่อ  
คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือ  
โฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรี  
ประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่า  
มีลักษณะบ่งเฉพาะ ในเรื่องนี้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่ง  
เฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 กำหนด  
หลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะว่า สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มี  
การจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร จน  
ทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและ  
เข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น เมื่อการนำสืบ

พยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้นั้นต้องเป็นพยานหลักฐานที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเครื่องหมายบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนนั้นมีความแตกต่างจากบริการอื่นก่อนวันที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียน พยานหลักฐานที่โจทก์อ้างส่งนั้นจึงต้องมีลักษณะเป็นทำนองที่แสดงให้เห็นถึงการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควรก่อนวันที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียน กรณีจึงไม่อาจนำหลักฐานการโฆษณาเผยแพร่หลังจากวันที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการมาพิจารณาประกอบความมีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้สำหรับคำขอจดทะเบียนคดีนี้ ประกอบกับในเอกสารโฆษณาบางส่วนก็เป็นการโฆษณาเครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD ประกอบคำว่า WD แตกต่างจากเครื่องหมายบริการที่ขอจดทะเบียน เครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD ของโจทก์จึงไม่เป็นเครื่องหมายที่ใช้กับบริการที่มีการจำหน่าย เผยแพร่ และโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานพอสมควรจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย รู้จักและเข้าใจว่าบริการของโจทก์แตกต่างไปจากบริการของบุคคลอื่น อันถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันเกิดจากการใช้จนแพร่หลายตามมาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสาม (เดิม)

---

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ พณ 0704/18359 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 297/2560 กับให้จำเลยดำเนินการรับจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD ตามคำขอเลขที่ 892112 ของโจทก์

## จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/34097 และ พณ 0704/18359 และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าที่ 297/2560 ให้นายทะเบียนเครื่องหมายการค้าดำเนินการเกี่ยวกับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าว่า MY CLOUD ตามคำขอเลขที่ 892112 ต่อไป ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

## จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชั้นอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางที่เพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ พณ 0704/34097 นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

## จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้แย้งกันในชั้นฎีการับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD เป็นคำขอเลขที่ 892112 สำหรับบริการจำพวกที่ 42 รายการบริการ 47 รายการ เช่น จัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ จัดหาซอฟต์แวร์สำหรับการเข้ารหัสและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ จัดหาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดดาวน์โหลดไม่ได้ จัดหาเฟิร์มแวร์ (ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ จัดหาซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

ออกแบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ออกแบบอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลซึ่งใช้หน่วยความจำแฟลช (แฟลชไดรฟ์) ออกแบบอุปกรณ์เก็บบันทึกข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ฮาร์ดไดรฟ์) พัฒนาหน่วยขับเคลื่อนบันทึกข้อมูล (ดิสก์ไดรฟ์) พัฒนาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลซึ่งใช้วงจรรวมเป็นหน่วยความจำ (โซลิดสเตตไดรฟ์) บริการเฝ้าสังเกตการณ์ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านการเข้าถึงจากระยะไกล บริการให้ใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ชนิดดาวน์โหลดไม่ได้ชั่วคราว นายทะเบียนเครื่องหมายการค้ามีคำสั่งไม่รับจดทะเบียนเนื่องจากเห็นว่าเครื่องหมายบริการดังกล่าวไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) เพราะคำว่า MY CLOUD แปลว่า เครือข่ายการติดต่อสื่อสารของฉัน เมื่อนำมาใช้กับบริการที่ยื่นขอจดทะเบียนจึงถึงถึงคุณสมบัติของบริการโดยตรง โจทก์อุทธรณ์คัดค้านคำสั่งของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า ต่อมาคณะกรรมการเครื่องหมายการค้ามีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่า พจนานุกรม Oxford River Books English-Thai แปลคำว่า MY ว่า ของฉัน และพจนานุกรมออนไลน์ [www.merriamwebster.com/dictionary/cloud](http://www.merriamwebster.com/dictionary/cloud) แปลคำว่า CLOUD หมายถึง the computers and connections that support cloud computing แปลว่า คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อที่สนับสนุนระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ทางอากาศ ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกระบบสำรองข้อมูล รวมกันสื่อความหมายได้ว่า คอมพิวเตอร์และระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ของฉัน เมื่อนำมาใช้กับบริการจำพวกที่ 42 ทำให้เข้าใจได้ว่าบริการภายใต้เครื่องหมายบริการดังกล่าวเป็นบริการที่เกี่ยวกับระบบสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของฉัน ถือเป็นคำที่ถึงถึงลักษณะของบริการโดยตรง เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) สำหรับหลักฐานที่โจทก์นำเสนอเป็นเพียงเอกสารแสดงการโฆษณาภายใต้เครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD ประกอบคำว่า WD ซึ่งแตกต่างจากเครื่องหมายบริการที่

ยื่นขอจดทะเบียน และเป็นข้อมูลแสดงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในปี 2557 เท่านั้น โดยไม่ปรากฏช่วงเวลาเผยแพร่หรือการโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานเท่าใดจึงรับฟังไม่ได้ว่าเครื่องหมายบริการที่โจทก์ยื่นขอจดทะเบียนมีการให้บริการเผยแพร่ หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควร จนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและเข้าใจว่าบริการของโจทก์แตกต่างไปจากบริการอื่น จึงมีคำสั่งยืนตามคำสั่งปฏิเสธของนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยซึ่งได้รับอนุญาตให้ฎีกาว่า เครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD ตามคำขอเลขที่ 892112 ของโจทก์เป็นเครื่องหมายบริการที่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนได้หรือไม่ ในส่วนประเด็นที่จำเลยฎีกาว่า แม้เครื่องหมายบริการของโจทก์ในภาคส่วนคำว่า CLOUD มีหลายความหมาย แต่ในการพิจารณาความหมายของคำในภาษาอังกฤษที่มีหลายความหมายต้องพิจารณาความหมายของคำประกอบกับรายการบริการที่ยื่นขอจดทะเบียนเป็นสำคัญสาธารณชนที่พบเห็นเครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD ของโจทก์ย่อมเข้าใจได้ทันทีว่า บริการภายใต้เครื่องหมายบริการของโจทก์เป็นบริการเครือข่ายการติดต่อสื่อสารของฉัน หรือเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ของฉันนับว่าเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะของบริการโดยตรง เครื่องหมายบริการของโจทก์จึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) นั้น เห็นว่า คำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการโดยตรงนั้นต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการอย่างตรงไปตรงมาจนถึงขนาดที่ว่าทำให้สาธารณชนทราบถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการทันที หรือหากสาธารณชนใช้วิจารณญาณเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจได้ เพราะ เป็นคำที่บรรยายหรือพรรณนาถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้า

หรือบริการนั้นโดยตรง คดีนี้เครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD ของโจทก์มีลักษณะเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดาประกอบด้วยสองภาคส่วน คือ ภาคส่วนคำว่า "MY" มีความหมายตามพจนานุกรม Oxford River Books English-Thai แปลว่า ของฉัน และภาคส่วน คำว่า "CLOUD" ซึ่งแม้โจทก์แก้ฎีกาอ้างว่า คำว่า "CLOUD" มีหลายความหมาย ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ และในส่วนความหมายที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ก็มีความหมายที่แตกต่างกัน ดังเช่นในชั้นนายทะเบียนเครื่องหมายการค้า คำว่า "CLOUD" ตาม [encyclopedia2.thefreedictionary.com](http://encyclopedia2.thefreedictionary.com) แปลว่า เครือข่ายการติดต่อสื่อสาร ส่วนในชั้นคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า แปลความหมายคำว่า "CLOUD" ตามพจนานุกรมออนไลน์ [www.merriamwebster.com/dictionary/cloud](http://www.merriamwebster.com/dictionary/cloud) ว่า คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อที่สนับสนุนระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ทางอากาศ คำดังกล่าวจึงไม่อาจสื่อได้แน่ชัดว่าหมายถึงสิ่งใด โดยพยานโจทก์ปากนายนั้นทนายผู้รับมอบอำนาจโจทก์ เบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น ว่า สาธารณชนทั่วไปที่เห็นคำว่า "CLOUD" ก็เพียงเข้าใจความหมายว่าเป็นก้อนเมฆ หรือปกคลุมด้วยเมฆ เท่านั้น แต่พยานโจทก์ปากดังกล่าวเบิกความด้วยว่า ในแวดวงผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์มีการนำคำว่า "CLOUD" ไปใช้กับระบบคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า cloud computing system ประกอบกับตามพจนานุกรม [www.merriamwebster.com/dictionary/cloud](http://www.merriamwebster.com/dictionary/cloud) คำว่า "CLOUD" หมายถึง the computers and connections that support cloud computing ด้วย ซึ่งคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าแปลว่า คอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อที่สนับสนุนระบบสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ทางอากาศ สอดคล้องกับที่โจทก์ก็ระบุในคำอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้าว่า cloud computing เป็นระบบการเก็บข้อมูลประเภทหนึ่งอันแสดงให้เห็นว่า เมื่อนำคำว่า "CLOUD" ไปใช้กับสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ สาธารณชนย่อมเข้าใจได้ว่าคำดังกล่าวมีความหมายแตกต่างจากความ

หมายที่แปลว่าก้อนเมฆหรือปกคลุมด้วยเมฆ ซึ่งจากพยานหลักฐานของโจทก์ก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่า โจทก์มุ่งเน้นที่จะใช้เครื่องหมายบริการดังกล่าวกับการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ และตามเอกสารการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของโจทก์ ก็อธิบายการทำงานของสินค้าหรือบริการของโจทก์ในลักษณะว่าเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวโดยจะมีฮาร์ดดิสก์บรรจุอยู่ภายในเครื่องที่สามารถเชื่อมต่อกับภายนอกได้ผ่านทางระบบเน็ตเวิร์กหรือระบบอินเทอร์เน็ตและมีบริการแอปพลิเคชันให้สามารถเข้าใช้งานคลาวด์ได้ จึงเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับ cloud computing โดยตรง เมื่อการพิจารณาว่าคำในเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการโดยตรงหรือไม่นั้น ต้องพิจารณาประกอบกับสินค้าหรือบริการที่ขอจดทะเบียน การที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการที่มีคำว่า "CLOUD" กับบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ สาธารณชนที่พบเห็นเครื่องหมายบริการของโจทก์ย่อมเข้าใจได้ในทันทีว่าเป็นบริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ดังนั้น คำว่า "CLOUD" จึงเป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง ไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะ ส่วนที่โจทก์แก้ไกว่า คำว่า "MY" ของโจทก์เป็นคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ มีความหมายว่า ของฉัน เมื่อประกอบคำว่า "CLOUD" ซึ่งมีได้มีความหมายเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว จึงเป็นการนำคำที่มีความหมายตามพจนานุกรมมาใช้อย่างอำเภอใจ (arbitrary) เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่าคำว่า "CLOUD" เป็นคำที่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการของโจทก์โดยตรง การที่โจทก์นำคำดังกล่าวมาประกอบกับคำว่า "MY" ในลักษณะเป็นอักษรโรมันตัวพิมพ์ใหญ่ธรรมดา แยกส่วนออกได้เป็นสองคำ โดยที่คำว่า "MY" มีความหมายว่า ของฉัน ซึ่งเป็นความหมายโดยทั่วไปไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับโจทก์ เมื่อนำมาใช้ประกอบกับคำว่า "CLOUD" จึงไม่ได้เป็นการนำคำที่มีความหมายตามพจนานุกรมมาใช้อย่างอำเภอใจตามที่กล่าวอ้าง

แต่กลับเป็นเครื่องหมายบริการที่ไม่มีลักษณะที่ทำให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการนั้นทราบหรือเข้าใจได้ว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างไปจากบริการอื่น

เครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD ของโจทก์โดยภาพรวมจึงไม่มีลักษณะบ่งเฉพาะอันพึงรับจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสอง (2) (เดิม) ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางโดยให้เหตุผลว่าเครื่องหมายบริการของโจทก์เป็นคำที่ไม่ได้เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของบริการโดยตรงนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยข้อนี้ฟังขึ้น

ส่วนที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่ได้จำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD จนแพร่หลายแล้วในประเทศไทยอันจะถือได้ว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้ตามพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 80 ประกอบมาตรา 7 วรรคสาม (เดิม) นั้น ประเด็นดังกล่าวศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษยังไม่ได้วินิจฉัยไว้ ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศเห็นควรวินิจฉัยไปโดยไม่ต้องย้อนสำนวน เห็นว่า พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 มาตรา 7 วรรคสาม (เดิม) บัญญัติว่า ชื่อ คำ หรือข้อความที่ไม่มีลักษณะตาม (1) หรือ (2) หากได้มีการจำหน่ายเผยแพร่ หรือโฆษณาสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้านั้นจนแพร่หลายแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด และพิสูจน์ได้ว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้นแล้ว ก็ให้ถือว่า มีลักษณะบ่งเฉพาะ ในเรื่องนี้ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องการพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะตามมาตรา 7 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534 กำหนดหลักเกณฑ์การพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะว่า สินค้าหรือบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นได้มีการจำหน่าย เผยแพร่หรือโฆษณาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควรจนทำให้สาธารณชนทั่วไปหรือสาธารณชนในสาขาที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยรู้จักและ

เข้าใจว่าสินค้าหรือบริการดังกล่าวแตกต่างไปจากสินค้าหรือบริการอื่น ประเด็นนี้ โจทก์นำสืบโดยมีนายนั้นทน ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ เบิกความประกอบบันทึกถ้อยคำ ยืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็น ว่า โจทก์เป็นผู้ผลิตฮาร์ดดิสก์ชั้นนำระดับโลกซึ่ง สาธารณชนทั่วไปและสาธารณชนผู้ใช้สินค้าต่างรู้จักผลิตภัณฑ์และบริการของโจทก์ ในชื่อ MY CLOUD และโจทก์ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์ประวัติความเป็นมาของ บริษัทภายใต้เครื่องหมายบริการ MY CLOUD ผ่านสื่อออนไลน์ของโจทก์ แต่หลัก ฐานดังกล่าวเป็นเพียงเอกสารแสดงประวัติของบริษัท การโฆษณาสินค้าหรือบริการ และช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการเท่านั้น โดยไม่ปรากฏว่าเริ่มมีการใช้ การโฆษณา หรือการจำหน่ายสินค้าหรือการให้บริการภายใต้เครื่องหมายบริการที่ยื่น ขอจดทะเบียนไว้ตั้งแต่เมื่อใด ส่วนที่โจทก์นำสืบว่า มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ใน เว็บไซต์สื่อออนไลน์รวมถึงหนังสือนิตยสาร แผ่นพับหนังสือพิมพ์ และการออกร้าน ขายสินค้าและให้บริการภายใต้เครื่องหมายบริการ MY CLOUD แต่โจทก์ยื่นคำขอ จดทะเบียนเครื่องหมายบริการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 พยานหลักฐานที่โจทก์ นำส่งเป็นเอกสารโฆษณาเผยแพร่สินค้าหรือบริการตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปี 2556 ซึ่งเป็นเวลาหลังจากวันที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเรื่อยมา เมื่อการนำสืบพยานหลัก ฐานเพื่อพิสูจน์ลักษณะบ่งเฉพาะจากการใช้นั้นต้องเป็นพยานหลักฐานที่พิสูจน์ให้เห็น ว่าเครื่องหมายบริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนนั้นมีความแตกต่างจากบริการอื่นก่อนวัน ที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียน พยานหลักฐานที่โจทก์อ้างส่งนั้นจึงต้องมีลักษณะเป็น ทำนองที่แสดงให้เห็นถึงการจำหน่าย เผยแพร่ หรือโฆษณาบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการที่โจทก์ขอจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานพอสมควรก่อนวันที่ โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียน กรณีจึงไม่อาจนำหลักฐานการโฆษณาเผยแพร่หลังจากวัน ที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายบริการมาพิจารณาประกอบความมีลักษณะ บ่งเฉพาะจากการใช้สำหรับคำขอจดทะเบียนคดีนี้ ประกอบกับในเอกสารโฆษณาบาง ส่วนก็เป็นการโฆษณาเครื่องหมายบริการคำว่า MY CLOUD ประกอบคำว่า WD

## หมายเหตุ